

1501071-37.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... da comercialização da droga para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501071-37.2020.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501071-37.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200648/2020 - DEL.POL.MIRASSOL, 13009194 - DEL.POL.MIRASSOL, 1763/20/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2200648 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA, LUCINEIA SURIAN, CAROLINE PINHEIRO e JOICE VALENTIM ADAO, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, assim como ao artigo 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 69 do Código Penal, por que segunda a denúncia, desde data incerta, mas anterior ao dia 15 de agosto de 2020, na Rua Olindo Botura, nº 10, esquina com a Avenida Doutor Modesto José Moreira, Portal da Cidade Amiga, neste Município e Comarca de Mirassol, os acusados associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a conduta capitulada no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta também que, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 00h10min, na Rua Olindo Botura, nº 10, esquina com a Avenida Doutor Modesto José Moreira, Portal da Cidade Amiga, neste Município e Comarca de Mirassol, os acusados transportaram, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 4 (quatro) grandes porções de Cannabis Sativa L ("maconha"), assim como nas mesmas circunstâncias de tempo FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA tinha em depósito e guardava no interior de sua residência, situada na altura do nº 1671 da Rua Prudente de Moraes, Centro desta Cidade de Mirassol, uma porção de "maconha", entorpecentes que somaram peso líquido total de 4.879,12g (quatro mil, oitocentos e setenta e nove gramas, e cento e vinte miligramas), tudo consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, laudo de constatação às fls. 51/53 e exame químico toxicológico de fls. 192/194.

A denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2020. Os acusados foram devidamente citados e apresentaram defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Houve audiência de Instrução por videoconferência e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Transcrevo o outro tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei. Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Transcrevo o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação".

Por fim, diz o artigo 69 do Código Penal: "Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela".

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.01, 25), pelo Boletim de Ocorrência (fls.02/05), pelo Termo de Depoimento (fls.06/07, 08), pelo Ofício de encaminhamento de preso (fls.28, 29, 30, 31), pelo Laudo Pericial (fls.51/53, 192/194, 600/604), pelo Auto de Interrogatório (fls.9, 10, 11 e 12), pela Nota de Culpa (fls.20, 21, 22), pelas fotografias (fls.47/50), pelo auto de exibição e apreensão (fls.17/19), pelo Relatório da Autoridade Policial (fls.195/196), pelo relatório de diligências (fls. 656/1507), bem como pela prova oral produzida.

Passo à análise da autoria.

O policial militar ADMILSON falou na Delegacia que "Que é 1º Sgt do 09º BAEP, e na presente data estava de plantão na companhia de seu colega de farda Lanza, os quais realizavam patrulhamento pelas ruas desta urbe, e durante patrulhamento no bairro Portal, se depararam com o veículo VW/Up, placas FQV2780, o qual apresentava avarias na lateral direita e no para-choque frontal, e aparentava estar "com carga", pois estava rebaixado, e ainda placa ostentada era do município de Catanduva, o que lhe chamou atenção, motivo pelo qual efetuaram a abordagem. A condutora do veículo se identificou por Joice, e disse que a proprietária do

veículo se tratava da passageira Caroline, ao serem indagadas se havia algo irregular no interior do veículo, disseram que não, ao efetuarem a abordagem foi localizado 04 tijolos aparentando ser maconhas no assoalho traseiro do veículo, onde estava sentados os passageiros Flávio, Lucinéia e a criança Maria Eduarda Valentim de Campos de 05 anos, que vem a ser filha de Joice. Novamente questionaram os ocupantes do veículo acerca da droga, que Caroline disse que teria saído da cidade de Catanduva e vindo para esta urbe, pois iria intermediar a venda de uma droga, e que ganharia a quantia de R\$100,00 por cada peça, para pagar o aluguel de sua casa, e que o contato com o vendedor teria sido feito pela sua amiga, Joice. Já Joice, disse que conheceu Flavio em datas anteriores, e na data de ontem, teria feito contato via telefone com Flávio, marcado um encontro para lhe entregar a droga para ser intermediada, e Lucinéia por vez, disse que veio passear com as amigas, que não tinha conhecimento da droga e Lucinéia disse que foi Flávio quem teria colocado a droga no veículo. Flávio nega a propriedade da droga no interior do veículo, alegando que pegou uma carona com as moças, questionado se havia alguma droga em seu imóvel, disse que havia droga em sua residência para uso próprio. Tanto Joice quanto Caroline indicaram o local aonde Flavio teria pego essa droga, dizendo que fora dentro de um tambor e adentrou no carro, local que coincide com a frente da casa de Flávio. Ato contínuo, Flávio franqueou a entrada da guarânia em sua residência, e apontou o guarda-roupa do seu quarto onde foi encontrado uma mochila preta, contendo em seu interior um tijolo aparentando ser maconha, uma balança de precisão, e várias embalagens plásticas utilizadas para embalar drogas. Diante dos fatos, as drogas, balança e os plásticos foram devidamente apreendidos e os envolvidos encaminhados a esta Unidade Policial onde foi lavrado o flagrante delito". Em Juízo, confirmou as declarações anteriores, disse também que "não conhecia as rés. A JOICE era condutora do veículo e a droga estava ao lado de FLAVIO. Os celulares dentro do veículo foram apreendidos. Ninguém imputou a droga a LUCINEIA, mas não tirou conclusão. O réu franqueou a entrada".

O policial militar REGINALDO na delegacia confirmou o depoimento de seu colega de farda Admilson. Em Juízo, confirmou as declarações anteriores, disse também que "CAROLINE admitiu a negociação da droga, sendo que JOICE falou que havia conhecido o FLAVIO e tinha ciência da droga. LUCINEIA falou que tinha ido passear com as amigas, passando na casa de FLAVIO. FLAVIO falou que nada sabia. A droga estava no carro no assoalho, em sacola transparente, visível a todos. LUCINEIA disse que viu FLAVIO entrando com as drogas. CAROLINE falou que FLAVIO entregaria para outras pessoas."

A testemunha de defesa LEANDRO, falou em Juízo que "conhece Flávio há uns três anos, o réu trabalha para ele há uns dois anos como ajudante geral. Sua conduta no trabalho era frequente e trabalhava de forma correta".

O réu FLÁVIO permaneceu calado na delegacia de polícia. Em Juízo disse que não é verdadeira a acusação. Falou que "conheceu a JOICE em dias anteriores, e combinaram de se encontrar para sair. Que quando ela chegou em MIRASSOL falou que tinha de passar em RIO PRETO. Ela perguntou se ele fumava maconha e respondeu que sim. A ré então lhe vendeu 1kg, porque é usuário. Não estava no banco de trás do veículo, mas sim na frente com JOICE. Como já tem passagem por tráfico, se soubesse de droga nem entraria no carro. Comprou mesmo a maconha, que estava em sua casa. Os policiais encontraram 4kg debaixo de uma caixa de som. JOICE não comentou que viria com as amigas. Não franqueou a entrada dos policiais em sua casa".

A ré LUCINEIA permaneceu calada na delegacia de polícia. Em Juízo disse que não é verdadeira a acusação. Falou que "nada sabia. Estava no carro com CAROLINE, que é a única que conhecia. Seu celular foi apreendido. Viu que FLAVIO entrou no carro com alguma coisa em mão".

A ré JOICE permaneceu calada na delegacia de polícia. Em Juízo disse que é parcialmente verdadeira a acusação. Falou que "a LUCINEIA ligou para CAROLINE dizendo precisar de 5kg de maconha para transportar a mando de alguém no presídio. Conhecia FLAVIO e entrou em contato com este para providenciar o pedido. LUCINEIA abasteceu o carro e foram. FLAVIO passou a droga para LUCINEIA. Esta não chegou a pagar o FLAVIO. A LUCINEIA ia receber o dinheiro da pessoa e pagar a elas R\$ 100,00 por peça. Fez por passar dificuldades. Existe registro entre celulares de LUCINEIA

e FLAVIO. Pede perdão por fazer isso na presença da filha, mas passava dificuldade. Foi a primeira vez que fez isso. Trocou mensagens pelo whatsapp com FLAVIO, com fins de relacionamento e este acabou por falar que era traficante, mandando fotos de drogas. Pegaram a LUCINEIA em Novo Horizonte e não entraram em RIO PRETO. FLAVIO sabia que levavam LUCINEIA para buscar droga, mas ele não a conhecia ". A ré CAROLINE permaneceu calada na delegacia de polícia. Em Juízo disse que é verdadeira a acusação. Falou que "a LUCINEIA foi casada com seu tio e se separaram. Também havia se separado e ido morar com JOICE. Que LUCINEIA ligou dizendo que precisava de droga com urgência, para pessoa. Falou com JOICE sobre o pedido e esta disse que conhecia FLAVIO, com quem conversava. LUCINEIA tinha pedido 5KG. FLAVIO falou que era difícil, mas arrumava 4kg. ESTAVAM sem dinheiro até para gasolina. Que pegaram emprestado para ir buscar LUCINEIA em NOVO HORIZONTE. Lá LUCINEIA abasteceu o carro. FLAVIO aceitou receber depois o pagamento, quando LUCINEIA recebesse do interessado. Todo mundo tinha ciência que dentro do carro havia droga. A menor estava no carro. No momento da abordagem falou com os policiais sobre LUCINEIA. Não sabe porque tal fato não constou em seus depoimentos. Não sabe porque LUCINEIA foi a única liberada. Procurou familiar do FLAVIO que conhece, mas não para combinar depoimento. Não conhece FLAVIO, mas ficou preocupada. Não conversava com FLAVIO pelo whatasapp, MAS morava com JOICE e sabia o que conversavam. Não usa mais droga. "

Diante de todo o conjunto probatório, de rigor a PARCIAL procedência da ação penal.

Quanto ao crime de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, este não restou configurado. Não houve prova segura nos autos acerca da estabilidade e divisão de tarefas entre os acusados.

Com relação ao crime de tráfico.

Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que fizeram a abordagem dos réus são similares e harmônicos entre si, incluindo aqueles dados na fase administrativa e reduzidos a termos. Disseram ainda que Flávio franqueou a entrada na residência. Os réus não apresentaram nada que possa justificar falsa acusação contra si. Já os policiais militares foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo quando do auto de prisão em flagrante.

Não há qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusar os réus injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova, e ainda, as rés Joice e Caroline descreveram com riqueza de detalhes a prática do crime, sendo ambos depoimentos semelhantes.

Além da palavra dos policiais e da confissão das rés Joice e Caroline, há o relatório de fls. 656/1507, referente à pericia nos telefones dos réus. Às fls. 656 no telefone da ré Lucineia foram localizados conteúdos de mídias relacionados a compra e venda de entorpecentes, há fotos, além de conversas, das quais descrevo alguns trechos: "... Então man, tô precisando p hj 5kl d verde...após há negociação de entrega e valores.... às fls. 666 há novas conversas sobre negociação e valores " o kl do verde ta qnto?....1600.... 5kl tem desc... tem cunhada quantas precisa". Às fls. 678 a conversa entre Lucineia e Caroline: "troquei de número e a Carol Ruiva, salvem ai.... Vc tem as manhas d conseguir 5 kl de verde p mim?... A vista ou a prazo... a vista amor... até na sexta.... e ai falou com o menino?... deu certo.... já encostada aqui... como assim mor.... deixa o cara q vou entregar encosta.... se vai vim aqui mor.... ou quer te busca...More tem q vir c os verdes toma la da cá em R. P tendeu.....tendeu o pq d levar a mercadoria já....ta bom mor quanto vc passou pra eles.... 2.000....Fx vêm.... Tamo indo então....." As fls. 701 o aparelho celular do réu Flávio foram localizadas imagens de drogas e armas de fogo, além de conversas sobre negociação de pagamento e entrega: "você não consegue arrumar mais uma, eles queriam 5....ai eu vou deixar esse contato para você, quando eles precisar ai você pega para você esse contato, entendeu? Eles pegam de bastante....não eu não vou levar no cpp eu vou levar para um cara ai entendeu? Ai eu te mando a localização ai você vai la me levar e você já pega o dinheiro....

você sabe quanto que vai dar em dinheiro? 6 mil, você esta ligada ne?..... eu sei vida, eu vou pegar o dinheiro com eles tá, eu te mando um salve que eu já to com dinheiro e você me fala onde que eu tenho que ir para pegar....com quem você tá vindo?.... eu estou indo de carro e tá indo eu e minha amiga.....a hora que você chegar em rio preto e der certo e chegar em Mirassol você me liga. Porque os baguio onde eu guardo minhas caminhadas é em Mirassol, você entendeu?. Às fls. 707 há a perícia no telefone da ré Caroline, onde foram localizadas imagens de drogas, bem como a conversa entre Lucineia e Caroline: "então mor, mas o único problema é que a gente precisava dar o dinheiro para o cara na hora, entendeu e agora o que nois faiz porque ele só vai soltar nois se tiver com o dinheiro.....então minha flor, mas nos vamos pegar o dinheiro lá, entendeu? Fls. 708, telefone de Lucineia com um homem desconhecido: " Deixa e falar um negócio para você, eu já falei para o parceiro lá, acho que o modo que eu trabalho é diferente de vocês, acho que o nosso negocio não vai dar certo não, eu só trabalho no toma la da ca, a gente marca um local, eu pego a mercadoria você conta moeda e parte, esse negocio de pegar moeda antes eu to fora...." Fls. 709, conversa entre Lucineia e Caroline: "então, aí você já deixa tudo separado de mil em mil que eu já to em conexão com o parceiro, é só desembolar a conexão aqui que nois já estamos colando.... Lu não tem 05 peças, mas tem 04 que já esta na cidade, será que eles abraçam as 04?.... você vai ta ganhando só 100 reais com isso aí, então fala para ela se pega 4 Lu, aí amanhã já pega o outro... nois vai pegar por R\$1.600,00 do cara...." Fls. 711 conversa entre Caroline e Thiago:" as meninas também precisam de maconha mas hoje elas já pegaram, elas saíram e buscaram mas pode deixar, vou avisar elas aqui já, para vocês abastecerem elas também na maconha.... vou levar aí para elas experimentar ver se elas gostam, você da para elas aí fumar demoro?.... deixa eu te fala, eu fui la no menino ele não tá... e aqui comigo, não vou ter da branca, só vou ter a que chegou da amarela é boa... a menina que tá aqui comigo deu uma e eu também dei uma agora, trava tudo os dentes se você quiser da amarela"...

O exame químico-toxicológico (fls.192/194) realizado nos entorpecentes encontrados em poder da ré resultou em positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância de uso proscrito no Brasil. Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas". (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315). Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA . IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras

condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise escorreita de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.”. (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012). Ainda: “TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.”. (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012).

Reconheço a causa de aumento de pena do inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, restou demonstrado havia uma criança de 05 anos no interior do veículo.

Diante de todo o exposto, considero que os réus praticaram o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar as penas, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, acrescida de ao menos 1/6.

Dosimetria do réu Flávio

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, fixo a pena base acima do mínimo legal, já que o réu possui maus antecedentes (fls.1580/1588). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.1581 – Processo nº 0004333-95.2017.8.26.0358; fls.1583 – Processo nº 0004946-62.2010.8.26.0358), pelo que aumento a pena em 1/6, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, impossível aplicar a redutora do §4º do art. 33 da lei de drogas, pela reincidência e maus antecedentes, contudo presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas. Houve depoimento seguro dos policiais quanto à circunstância da presença da menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

O regime carcerário será inicialmente o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando também a reincidência.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

O réu não tem direito a benefícios que substituem a pena privativa de liberdade, principalmente por não preencher os requisitos subjetivos do artigo 44, e do artigo 77, ambos do Código Penal.

Além disso, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06: “Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”.

Dosimetria da ré Lucineia.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois nada há em sua certidão (fls. 1591/1592).

Na segunda fase, nada há que ser considerado.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas. Houve depoimento seguro dos policiais quanto a circunstância da presença da menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes da ré. Assim reduzo aquém do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sendo a ré é primária.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica da ré, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal).

Dosimetria da ré Caroline.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois nada há em sua certidão (fls.1555/1556).

Na segunda fase, nada há que ser considerado.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas. Houve depoimento seguro dos policiais quanto a circunstância da presença da menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes da ré. Assim reduzo a quem do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo a ré é primária.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica da ré, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal).

Dosimetria da ré Joice.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois nada há em sua certidão (fls.1559/1560).

Na segunda fase, nada há que ser considerado.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas. Houve depoimento seguro dos policiais quanto a circunstância da presença da menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes da ré. Assim reduzo a quem do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo a ré é primária.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica da ré, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e assim: (i) CONDENO o réu FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial FECHADO; (ii) CONDENO as rés LUCINEIA SURIAN, CAROLINE PINHEIRO e JOICE VALENTIM ADAO, como incursas no artigo 33, caput c.c

artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e, reconhecido o privilégio do §4º do mesmo dispositivo legal, a cumprir a pena 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial ABERTO, SUBSTITUIDA a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação. As penas pecuniárias deverão ser atualizadas pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal; (iii) ABSOLVO os réus FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA, LUCINEIA SURIAN, CAROLINE PINHEIRO e JOICE VALENTIM ADAO, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, das imputações de lhes foram feitas na denúncia quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

A prisão cautelar do réu FLÁVIO deve ser mantida. A quantidade de entorpecentes apreendida em sua posse demonstram que seria impossível ficar em liberdade sem prejudicar a ordem pública. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra.

Determino a destruição dos celulares, balança de precisão, embalagens plásticas, (fls.17/19), nos termos do artigo 516, § 2º, NSCGJ.

Quanto ao veículo apreendido (Fls.18), automóvel VW/UP, placas FQV2780 declaro o seu perdimento, pois utilizado na prática do crime. Assim, expeça-se o necessário para alienação na forma do art. 61 da Lei 11.343/06.

Por fim, quanto ao entorpecente apreendido (fls.17/19), verifico que já foram destruídos (fls.296/302). Oficie-se à delegacia de polícia determinando a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando-se nos autos.

Custas "ex lege". Ao defensor nomeado, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão.

P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Mirassol, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA